

第 5 部

基礎法学

▶ 科目別ガイダンス	678
------------------	-----

第1章 法学概論	680
----------------	-----

第1節 法とは何か ※	680
-------------------	-----

第2節 法の効力	685
----------------	-----

第3節 法の解釈	688
----------------	-----

第4節 法律用語 ※	690
------------------	-----

第2章 紛争解決制度	694
------------------	-----

第1節 裁判制度 ※	694
------------------	-----

第2節 裁判外紛争解決手続	703
---------------------	-----

※は『スタートダッシュ』掲載テーマです。

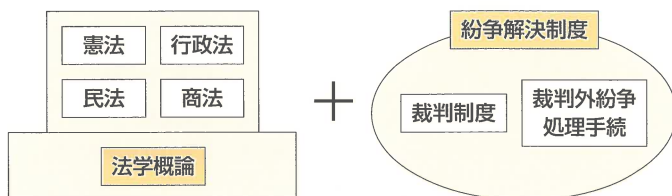
科目別ガイドンス

1 基礎法学とは何か

基礎法学とは、**法律を学ぶ上で知っておくべき基礎的な事項**のことです。つまり、法律の規定を読み進めていくために必要となる知識（例：法律用語の意味）のことです。学問上ではこれを**法学概論**といいます。

もっとも、行政書士試験における基礎法学の問題では、法学概論のみならず、裁判制度や裁判外紛争処理手続のような**紛争解決制度**がよく出題されています。これは、純粋な意味での基礎法学とは若干異なりますが、実際に出題されている以上、行政書士試験においては基礎法学に含まれるものと考えておきましょう。

【行政書士試験における基礎法学】



2 出題傾向表

10年間（平成24年度～令和3年度）分の本試験の出題傾向を表にまとめました。なお、平成29年度は、犯罪論（罪刑法定主義）、法思想といったマイナーなテーマからの出題でしたので、出題傾向表は空欄になっています。

（1）法学概論

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
法とは何か	○						○			
法の効力										○
法の解釈		○								
法律用語	○		○							

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

(2) 紛争解決制度

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
裁判制度		○		○	○			○	○	
裁判外紛争処理手続									○	

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

3 分析と対策

(1) 学習指針・学習内容

基礎法学は、具体的な条文があるわけではなく出題範囲がわかりづらい上に、例年2問（8点）しか出題されないことから、深入りすべきでない科目といえます。また、基礎法学は、法律用語、裁判制度の出題頻度が若干高いという点を除き、全範囲から満遍なく出題されていますので、ヤマを張るのも難しい科目です。

他方で、基礎法学は、他の法令科目を学習していれば正解できるような問題が出されることも少なくありません。その点で、改めて対策をする必要性もそれほど大きくないものといえます。

そこで、基礎法学については、あまり多くの時間を割かずに、**過去問で出題された知識を押さえる程度にとどめる**とよいでしょう。2問とも正解しようとするのではなく、1問正解できれば十分といった割り切りが必要な科目といえます。

(2) 得点目標

基礎法学は、**5割正解**できれば十分でしょう。

【基礎法学の得点目標】

出題形式	出題数	得点目標
5肢択一式	2問（8点）	1問（4点）

第1章 法学概論

第1節 法とは何か

重要度 B

学習のPOINT

ここでは、社会規範のうち「法」と「道徳」の違いについて学習していきます。また、「法」については、より詳しく学習していきます。

1 法と道徳

人間は他人とまったく無関係に生きることはできず、他人とともに社会生活を営むことになります。もっとも、社会生活の中で1人1人が自分のしたいように行動していたら、他人との間で争いが生じ、社会秩序が乱れてしまいます。

そこで、社会秩序を維持するため、社会生活においては「～しなければならない」「～してはならない」といった一定のルールが必要となります。これを**社会規範**といいます。

社会規範には、大きく分けて**法**と**道徳**の2つがあります。両者の違いは以下のとおりです。

【法と道徳】

	法	道徳
意味	国家という政治社会において政治的権力作用を背景に強制される社会規範	善を理念として誠実・仁義等の多面的な価値判断をなす社会規範 ※1
特徴	①国家による制裁（サンクション）を伴うものである ②人間の外面的な行為に関係する規範 ③法的義務には原則として相手方が存在する ④法的義務は他の動機に基づいて行われることを許容する	①国家による制裁（サンクション）を伴うものではない ②人間の内心に関係する規範 ③道徳上の義務には相手方が存在しない ④道徳上の義務はそれが自らの意思により行われることを要求する

※1 具体例をイメージ

例えば、「人には親切にすべきである」といったものである。

2 成文法（制定法）

法は、文字・文章で表現され所定の手続に従って定立される**成文法（制定法）**と、社会における実践的慣行を基礎として生成する**不文法**とに大別されます。

（1）成文法主義

成文法は、日本のような成文法主義をとる大陸法系諸国においては、原則として他の諸々の法源※2に優先する第一順位の法源として中心的な地位を占めています。※3

そして、成文法主義は、社会の構成員に行動基準を指示し、裁判官に裁判の基準を明確に示すのに役立つという長所がある半面、時代の変化には即応しにくいという短所があります。

（2）成文法の分類

① 公法・私法・社会法

	意味	具体例
公法	国家の統治権の発動に関する法	憲法、行政法、刑法※4、訴訟法※5
私法	私人間の法律関係を規律する法	民法、商法
社会法	生存権理念に基づき、私的自治に対する国家権力又は集团的自治による制限を定める法	労働法、社会保障法

② 実体法と手続法 図30-2-イ

	意味	具体例
実体法	権利・義務の種類・変動・効果を規律する法	民法、刑法、商法
手続法	実体法を具体的事件に適用する手続に関する法	訴訟法、不動産登記法、戸籍法

（3）成文法相互の関係

① 上位法と下位法

成文法には、上下関係があります。以下の表は、上位法から下位法へと並べてあります。

※2 用語

法源：法の存在形式のこと。

※3 参考

判例法主義をとる英米法系諸国でも、制定法は判例法に優先し、判例を変更する効力が認められている。

※4 用語

刑法：どのような行為が犯罪となり、犯罪に対してどのような刑罰が科されるかを定めた法律のこと。

※5 用語

訴訟法：訴訟を規律する法律の総称のこと。具体的には、行政事件訴訟法・民事訴訟法・刑事訴訟法などがある。

【成文法の上下関係】

憲法		国の根本について定めた法
法律		国会が制定した法
命令	政令	内閣が制定した法
	内閣府令	内閣総理大臣が制定した法
	省令	各省大臣が制定した法
	規則	委員会（公正取引委員会※1など）や庁の長官（国税庁長官など）が制定した法 図21-1-ア
条例		地方公共団体の議会が制定した法 図21-1-ア
規則		地方公共団体の長（都道府県知事・市町村長など）が制定した法 図21-1-ア

※1 用語

公正取引委員会：独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）の運用に当たる委員会のこと。

※2 具体例をイメージ

例えば、一般市民の取引について規定した民法は一般法、会社などの商人の取引について規定した商法は特別法となり、商法が民法に優先して適用される。

※3 参考

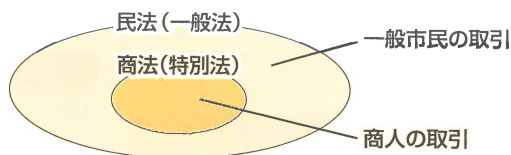
前法が後法の特別法に当たる場合は、前法が後法に優先する。 図20-1-5、3-2-4

② 一般法と特別法

一般法とは、ある事項について一般的に規定した法令のことであり、**特別法**とは、同じ事項について特定の場合又は特定の人・地域に限って適用される法令のことです。 ※2 図30-2-ウ

一般法と特別法の間では、特別法が一般法に優先して適用され、一般法は特別法に規定のない事項についてのみ補充的に適用されます。 図21-1-イ

【一般法と特別法】



③ 前法と後法

時間的に後に制定された法（**後法**）は、先に制定された法（**前法**）に優先して適用されます。 ※3 図21-1-イ

④ 基本法

教育基本法、環境基本法など「基本法」という名称を持つ法律であっても、各議院の**通常の多数決**を経て制定されます。また、通常の法律をもって基本法の規定を改廃することもできます。 図21-1-ウ

3 不文法

不文法には、以下のような種類があります。

(1) 判例

① 判例とは何か

判例とは、先例として機能する裁判例・判決例のことです。※4

判例は、一般的見解によれば、**英米法系**の国では後の事件に対して法的な拘束力を有する法源とされてきましたが、**大陸法系**の国では法源とはされてきませんでした。図24-1-1

しかし、日本では、大陸法系の国と同様に成文法主義をとっているにもかかわらず、先例としての判例に従うことが裁判実務上の慣行となっており、判例も法源とされています。※5

② 判決理由の拘束力

英米法系の国では、判決理由のうち結論を導く上で必要な部分を**レイシオ・デシデンダイ**、それ以外の部分を**傍論（オビタ・ディクタム）**と呼び、前者には判例法としての拘束力を認めていますが、後者にはこれを認めていません。図24-1-2

(2) 慣習法 ※6

① 慣習法とは何か

慣習法とは、社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会の構成員がそのような慣習を自分たちの行動の正当化理由として用いることによって法として確信するようになった場合に成立するもののことです。図30-2-1

② 慣習法の要件

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、**法律と同一の効力**を有します（法の適用に関する通則法3条）。

③ 任意規定と異なる慣習

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、**その慣習**に従います（民法92条）。

※4 参考

判例という語は、広義では過去の裁判例を広く指す意味でも用いられ、この意味での判例に含まれる一般的説示が時として後の判決や立法に大きな影響を与えることがある。図24-1-3

※5 参考

下級審が最高裁判所の判例に反する判決を下した場合、最高裁判所は申立てに対して上告審として事件を受理することができる（民事訴訟法318条1項）。図24-1-4

※6 参考

国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものがあり、明示のものは条約であり、黙示のものは国際慣習法であって、この両者が国際法の法源となる。

このように、民法は、強行規定ではなく、**任意規定**（公の秩序に関しない規定）に関して、慣習が法律行為の基準として実質的に法源となることを認めています。

④ 商慣習

商事に関しては、商法に定めがない事項については**商慣習**に従い、商慣習がないときは、**民法**の定めるところによるとされています（商法1条2項）。 28-36-2

⑤ 慣習刑法の禁止

犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければなりませんから（これを**罪刑法定主義**といいます）、慣習法は刑法の直接の法源とはなり得ません。

(3) 条理

条理とは、社会生活において相当多数の人々が一般的に承認している道理・筋道のことです。 1

日本では、1875年（明治8年）の太政官布告103号裁判事務心得3条が条理の法源性を認めた根拠とみられています。

※1 参考

民事裁判では、適用すべき法律がない場合、条理に従って裁判すべきであるが、刑事裁判では、適用すべき法律がない場合、条理に従って裁判することはできず、罪刑法定主義に従って無罪判決を下すべきとされている。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ 1 日本において、他の諸々の法源に優先する第一順位の法源として中心的な地位を占めているのは、判例法である。
- ☐ ☐ ☐ 2 一般法と特別法の間では、一般法が特別法に優先して適用される。
- ☐ ☐ ☐ 3 商事に関しては、商法に定めがない事項については民法の定めに従い、民法の定めがないときは、商慣習の定めるところによる。

解答

 ☒ 成文法である。  ☒ 特別法が一般法に優先して適用される。  ☒ 商慣習と民法の順序が反対である（商法1条2項）。



学習のPOINT

ここでは、法はどのような範囲で効力を生じるのかについて見ていきます。基礎法学の中では出題頻度が高いテーマなので、しっかりと学習しておきましょう。

1 時間的適用範囲

(1) 発生時期

法は、**公布**※2され、かつ**施行**※3された日（施行期日）から国民に対する効力を生じます。※4 図23-1-3

なお、法令は、その**附則**において、施行期日について規定していることが通例です。

【公布・施行がなされる日】

	公布がなされる日	施行がなされる日
法律	奏上の日から 30日 以内に公布しなければならない（国会法66条）	施行期日の定めがあるときを除き、公布の日から起算して 20日 を経過した日から施行される（法の適用に関する通則法2条） 図20-1-3、3-2-2
条例	普通地方公共団体の長は、条例の送付を受けた場合には、再議その他の措置を講じた場合を除き、その日から 20日 以内にこれを公布しなければならない（地方自治法16条2項） 図26-23-4	特別の定めがあるものを除き、公布の日から起算して 10日 を経過した日から施行される（地方自治法16条3項）

(2) 失効時期

法は、原則として、**改廃**されるまで国民に対する効力を生じます。

もっとも、有効期間が限定されている**限時法**の場合、その期間が経過すると失効します。図23-1-2、3-2-5

(3) 遡及適用

法は、原則として、**遡及して**適用することができません。し

※2 用語

公布：成立した法令を国民一般に周知させる目的で公示する行為のこと。慣行として官報によることとされている。

※3 用語

施行：法令の効力を現実に発生させること。

※4 参考

施行期日の定めにより、法令が公布日から施行されることもある。図3-2-1

たがって、法に規定された罰則が、施行期日前の事実につき行為者に不利に適用されることはありません。※1 ※2

もっとも、適用される者にとって**有利**な場合には、遡及適用が認められます。

2 場所的適用範囲

(1) 属地主義の原則

日本の法令は、原則として、日本の領域内にいるすべての人に対して効力を有します(これを**属地主義**といいます)。※3 ※4

過20-1-1、23-1-1

(2) 属地主義の例外

属地主義の例外としては、以下のようなものがあります。

① 属人主義

属人主義とは、その人の属する国の法令が、その人が国内にいるか国外にいるかを問わず適用されるというルールのことです。※5

② 保護主義

保護主義とは、国益を保護するため、その人の国籍や、その人が国内にいるか国外にいるかを問わず、法令を適用するというルールのことです。※6

③ 旗国主義

日本に属する**船舶・航空機内**では、外国の領域内や公海においても日本の法令が効力を有することがあります(刑法1条2項)。過20-1-1、3-2-3

④ 治外法権

外国の外交使節等の**治外法権**は、属地主義の例外とされています。

⑤ 地方自治特別法

地域の特性に鑑み特別の地域に限って規制を行ったり、規制の特例措置をとったりする**地方自治特別法**も認められています。過23-1-4

※1 参考

法令に違反する行為に対して刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合には、その法令の失効後においても処罰を行うことができる。過20-1-4

※2 参考

法律の廃止に当たって廃止前の違法行為に対し罰則の適用を継続する旨の規定をおくことは許される。過23-1-5

※3 具体例をイメージ

例えば、外国人が日本において窃盗罪を行った場合、日本の刑法が適用される(刑法1条1項)。

※4 参考

渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある(法の適用に関する通則法36条、38条)。他方、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うこともある(法の適用に関する通則法41条本文)。過20-1-2

※5 具体例をイメージ

例えば、日本人が日本国外において殺人罪などの重大犯罪を行った場合、日本の刑法が適用される(刑法3条)。

例えば、外国人が日本国外において内乱罪や通貨偽造罪などの日本の国益を害する犯罪を行った場合、日本の刑法が適用される（刑法2条）。18-2-イ

確認テスト

- ☐☐☐ 1 法は、公布された日から国民に対する効力を生じる。
- ☐☐☐ 2 法は、原則として遡及して適用することができる。
- ☐☐☐ 3 日本の法令は、原則として、日本の領域内にいるすべての人に対して効力を有する。
- ☐☐☐ 4 日本に属する船舶・航空機内では、外国の領域内や公海においても、日本の法令が効力を有することがある。

解答 1 × 施行されることも必要である。 2 × 原則として遡及して適用することができない。 3 ○ 属地主義の原則である。 4 ○ （刑法1条2項）



学習のPOINT

法の解釈は、各種の論理解釈の手法の意味とその具体例を一読して押さえておけば十分です。

1 法の解釈とは何か

法の解釈とは、法の内容を明らかにすることです。法の適用にあたっては、法の解釈という作業が必要になります。

法の解釈においては、**法的安定性**の要請（人・事物・状況等の差異をあまり考慮せず、画一的な解決をせよとの要請）と**具体的妥当性**の要請（差異に応じたきめの細かい扱いをせよとの要請）を調和させなければなりません。※1

2 法の解釈の種類

(1) 文理解釈

文理解釈とは、法規の文字・文章の意味を通常の意味や文法に従って解釈することです。

(2) 論理解釈

論理解釈とは、法規の文字・文章の意味を論理の法則に従って明らかにすることです。

論理解釈には、以下の5種類があります。

【論理解釈】

	意味	具体例
拡大解釈 ※2	法規の文字・文章の意味を常識的意味よりも広げて解釈すること ②	刑法38条3項本文の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」との規定にいう「法律」とは、法律のほか、政令・省令・条例・規則など一切の法令を含むとする解釈

※1 参考

行政法においては一般的に法的安定性の要請が強調され、民法においては一般的に具体的妥当性の要請が強調される。

※2 参考

法規の条文を拡大解釈することも認められている。

縮小解釈	法規の文字・文章の意味を限定して狭く解釈すること 図25-1-5	民法754条本文の「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」との規定にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続しているというだけでなく、実質的にもそれが継続していることをいうとする解釈
類推解釈 ※3	ある事項を直接に規定した法規がない場合に、それと類似した事項について規定した法規を間接的に適用すること 図25-1-3	債務不履行による損害賠償について賠償すべき損害の範囲を定めた民法416条の規定は、不法行為による損害賠償についても適用されたとする解釈である。
反対解釈	ある事項を直接に規定した法規がない場合に、他の事項について規定した法規と反対の結論を導き出すこと 図25-1-1	民法96条3項に「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」とあることから、強迫による意思表示の取消しであれば、善意でかつ過失がない第三者にも対抗できるとする解釈
もちろん 勿論解釈	法規の文字・文章の意味から当然考えられる事項を導き出すこと 図25-1-2	公園の入口にある「自転車の乗り入れを禁止する」という看板を見て、その「自転車」とは「自転車に乗った人」のことであるとする解釈

※3 参考

刑法においては、罪刑法定主義に反することから、類推解釈をすることは許されないのが原則である。もっとも、被告人に有利な類推解釈をすることは許される。

確認テスト

- ☐☐☐ 1 類推解釈とは、法規の文字・文章の意味を常識的意味よりも広げて解釈することである。
- ☐☐☐ 2 債務不履行による損害賠償について賠償すべき損害の範囲を定めた民法416条の規定は、不法行為による損害賠償についても適用されたとする解釈は、反対解釈である。

解答 1 × 拡大解釈である。 2 × 類推解釈である。



学習のPOINT

法律用語については、出題頻度が高いだけでなく、他の法令科目の条文を読む際にも役立ちますので、じっくりと学習しておきましょう。

1 段階的な使い方がなされる法律用語

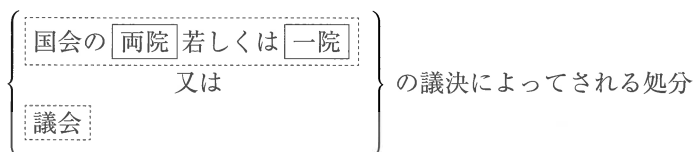
(1) 又は・若しくは

選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番大きな選択的接続に「**又は**」を用い、その他の小さな選択的接続には「**若しくは**」を用います。📖22-1、26-2-2 ※1

選択される語句に段階がない場合には、「又は」を用います。

【「又は」「若しくは」の使い方】

「国会の両院**若しくは**一院**又は**議会の議決によってされる処分」(行政手続法3条1項1号)



(2) 及び・並びに

並列される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番小さな並列的接続に「**及び**」を用い、その他の大きな並列的接続には「**並びに**」を用います。📖26-2-1

並列される語句に段階がない場合には、「及び」を用います。

【「及び」「並びに」の使い方】

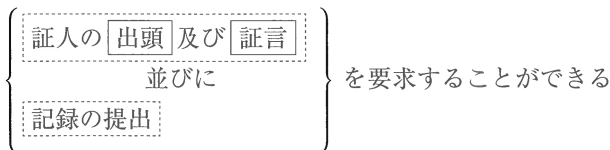
「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭**及び**証言**並びに**記録の提出を要求することができる。」(憲法62条)

※1 過去問チェック

「又は」と「若しくは」は、いずれも前後の語句を選択的に連結する接続語であり、選択される語句に段階がある場合には、一番大きな選択的連結にだけ「**又は**」を用い、他の小さな選択的連結には全て「**若しくは**」を用いる。→○(26-2-2)

※2 具体例をイメージ

例えば、民法721条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定しているが、これは、胎児の損害賠償請求権については、既に生まれた人と同一に扱うということである。



2 意味の紛らわしい法律用語

(1) みなす・推定する 図20-2-ア・イ

「**みなす**」とは、本来性質が違うものを同一のものとして法律が認め、同一の効果を生じさせることです。※2

これに対して、「**推定する**」とは、ある事実について、当事者間に取決めがない場合や反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下し、そのような取扱いをすることです。※3

このように、「みなす」の場合、反対の証拠が挙がっても取扱いは覆りませんが、「推定する」の場合、反対の証拠が挙げれば取扱いが覆ります。

(2) 適用する・準用する・例による 図26-2-4

「**適用する**」とは、その規定が本来の目的としている対象に対して当該規定をあてはめることです。

これに対して、「**準用する**」とは、他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えてあてはめることです。※4 図20-2-ウ

また、「**例による**」とは、1つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめることです。※5 図20-2-エ

(3) 違法・不当

「**違法**」とは、法に違反することです。

これに対して、「**不当**」とは、その行為又は状態が実質的に妥当性を欠くことをいい、必ずしも違法であることを要しません。

(4) 権限・権原

「**権限**」とは、ある法律行為又は事実行為をすることができる能力のことです。

これに対して、「**権原**」とは、ある法律行為又は事実行為を

※3 具体例をイメージ

例えば、民法573条は、「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」と規定しているが、これは、売買の目的物の引渡期限が3月1日とされていた場合、当事者間に取決めがなく反対の証拠も挙がらなければ、代金の支払期限も3月1日となるということである。

※4 具体例をイメージ

例えば、不可分債務に関する民法430条は、連帯債務に関する民法436条（「…数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、…全部…の履行を請求することができる。」）を準用しているから、「…数人が不可分債務を負担するときは、債権者は、その不可分債務者の1人に対し、…全部…の履行を請求することができる。」ということになる。

※5 参考

法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項について包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときには、「なお従前の例による」という表現が用いられる。図20-2-オ

することを正当であるとする法律上の原因のことです。

(5) 侵す・犯す

「**侵す**」とは、権利又は自由を害することです。

これに対して、「**犯す**」とは、刑罰法規において罪とされる行為をすることです。

(6) 期限・期間

「期限」と「期間」とは、共にある時間的な長さをもつ観念ですが、「**期限**」は、始期以後又は終期以前における不定の時間的広がりをもつのに対し、「**期間**」は、その始期と終期の間の一定の時間的長さである点で差異があります。

(7) 遅滞なく・直ちに

「遅滞なく」と「直ちに」とは、いずれも時間的遅延を許さない趣旨の用語ですが、「**遅滞なく**」においては、正当な、又は合理的な理由による遅延は許容されるものと解されているのに対し、「**直ちに**」においては、一切の遅延が許されないものと解されています。^{※1}

(8) 規定・規程

「**規定**」とは、法令における個々の条項の定めのことです。

これに対して、「**規程**」とは、法令における一連の条項の総体のことです。

(9) 以上・超える、以下・未滿

「**以上**」とは、基準となる数量を含んでそれより多いことであり、「**超える**」とは、基準となる数量を含まないでそれより多いことです。

また、「**以下**」とは、基準となる数量を含んでそれより少ないことであり、「**未滿**」とは、基準となる数量を含まないでそれより少ないことです。

(10) その他・その他の 26-2-3

「**その他**」は、前後の語句を並列の関係に並べる場合に用いる用語です。例えば、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係にあります。

これに対して、「**その他の**」は、後の語句が前の語句を含むより広い意味を持つ場合（前の語句が後の語句の例示である場

※1 参考

「速やかに」も時間的遅延を許さない趣旨の用語であり、「直ちに」よりは時間的な緊急度が低く、「遅滞なく」よりは時間的な緊急度が高い。 26-2-5

合)に用いる用語です。例えば、「A、Bその他のX」とある場合には、A、Bは、Xの例示としてXに包含されます。

確認テスト

- ☐☐☐ ① 選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番大きな選択的接続に「若しくは」を用い、その他の小さな選択的接続には「又は」を用いる。
- ☐☐☐ ② 「みなす」の場合、反対の証拠が挙げられても取扱いは覆らないが、「推定する」の場合、反対の証拠が挙げられれば取扱いが覆る。
- ☐☐☐ ③ 「権限」とは、ある法律行為又は事実行為をすることを正当であるとする法律上の原因のことである。
- ☐☐☐ ④ 「以上」とは、基準となる数量を含んでそれより多いことであり、「超える」とは、基準となる数量を含まないでそれより多いことである。

解答 ①×「又は」と「若しくは」が反対である。②○ ③×「権限」ではなく「権原」である。④○

第2章 紛争解決制度

第1節 裁判制度

重要度 **A**

学習のPOINT



裁判制度は、基礎法学の中でも一番の頻出テーマです。出題範囲の絞りにくい基礎法学において、安定した得点の見込める分野ですので、しっかり学習しておきましょう。

1 裁判とは何か

裁判とは、司法機関としての裁判所・裁判官が現実の紛争を解決する目的でなす公権的な法的判断の表示のことです。

裁判には、大きく分けて、私人間の権利義務に関する紛争を解決する**民事裁判**と、犯罪を行った者の処罰を求める**刑事裁判**があります。❶

【民事裁判と刑事裁判】

	民事裁判	刑事裁判
訴える人	原告	検察官
訴えられる人	被告	被告人

❶ 参考

民事裁判の手続については民事訴訟法が、刑事裁判の手続については刑事訴訟法が、それぞれ定めている。

2 裁判の基本原則

(1) 当事者主義

当事者主義とは、主張・立証の主導権を裁判の当事者に委ね、裁判官は審判の立場からその過程を整理して、最終的に優劣を判断するにとどめる原則のことです。日本では、民事裁判においても刑事裁判においても、当事者主義が採用されています。

(2) 自由心証主義

自由心証主義とは、裁判所が証拠に基づき事実認定をするに当たり、裁判官の自由な判断に委ねる原則のことです。日本では、民事裁判においても刑事裁判においても、自由心証主義が採用されています（民事訴訟法247条、刑事訴訟法318条）。

したがって、ある事件について民事裁判と刑事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において異なる事実認定がなされることもあります。

(3) 証明責任（挙証責任）

裁判所は、法令の適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできません。

そこで、このような場合には、その事実を存否いずれかともなして当事者のどちらかに不利な判決をせざるを得ないことになります。この当事者の負う不利益のことを**証明責任（挙証責任）**といいます。

民事裁判においては、**一定の法律効果を主張する当事者**が、その効果の発生に必要な事実（要件事実）につき証明責任を負います。**※2**

これに対して、刑事裁判では、原則として**検察官**が挙証責任を負います。これは、刑事裁判においては、被告人の人権保障の観点から「**疑わしきは被告人の利益に**」の原則が採用されているためです。

3 裁判所・裁判官

(1) 裁判所

裁判所は、**最高裁判所**と**下級裁判所**に大別されます。**※3**

① 最高裁判所

最高裁判所は、**大法院****※4**又は**小法院****※5**のいずれかで審理を行うかを自由に決定できるのが原則です（裁判所法10条本文）。

もっとも、以下の場合には、大法院で裁判を行わなければなりません（裁判所法10条ただし書）。**図**19-1-5 **※6**

※2 具体例をイメージ

例えば、売買代金の支払いを請求する者は、売買契約の成立という要件事実を証明する責任を負う。

※3 参考

最高裁判所の裁判では少数意見を付すことができるが（裁判所法11条）、下級裁判所の裁判では少数意見を付すことはできない。**図**23-2-3

※4 用語

大法院：全員の裁判官の合議体のこと。

※5 用語

小法院：最高裁判所の定める員数（3人以上）の裁判官の合議体のこと。

※6 過去問チェック

最高裁判所は、大法院または小法院で審理を行うが、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法院で裁判しなければならない。**→○**（19-1-5）

【大法廷で裁判を行う必要のある場合】

1	当事者の主張に基づいて、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かを判断するとき（意見が前に大法廷でした合憲判決と同じであるときを除く）（憲法判断）
2	法律・命令・規則・処分が憲法に適合しないと認めるとき（違憲判断）
3	憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき（判例変更） 24-1-5

② 下級裁判所

下級裁判所には、**高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所**の4種類があります（裁判所法2条1項）。

それぞれの裁判所の権限及び担当裁判官の数は、以下のとおりです（細かい例外は省略しています）。

【各裁判所の権限及び担当裁判官の数】

	権限	担当裁判官の数
高等裁判所	①地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 ②地方裁判所・家庭裁判所の決定・命令、簡易裁判所の刑事に関する決定・命令に対する抗告 ③地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告（刑事に関するものを除く） （裁判所法16条）	3人の裁判官による合議制（裁判所法18条） 19-1-3
地方裁判所	①簡易裁判所・家庭裁判所以外の訴訟の第一審 ②罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審 ③簡易裁判所の判決に対する控訴（刑事に関するものを除く） ④簡易裁判所の決定・命令に対する抗告（刑事に関するものを除く） （裁判所法24条）	3人の裁判官による合議制で行われる場合を除き、 1人の裁判官 （裁判所法26条） 19-1-3

簡易 裁判所 過 19-1-4	①訴訟の目的の価額が 140万円を超えない 請求 ②罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪に係る訴訟の第一審の裁判 (裁判所法33条1項)	1人の裁判官 (裁判所法35条)
家庭 裁判所 過 23-2-5	①家庭に関する事件の審判・調停 ②人事訴訟 ※1 の第一審の裁判 ③少年の保護事件 ※2 の審判 (裁判所法31条の3第1項)	3人の裁判官による合議制で行われる場合を除き、 1人の裁判官 (裁判所法31条の4) 過 19-1-3

(2) 裁判官

① 種類

最高裁判所の長たる裁判官を**最高裁判所長官**といい、その他の裁判官を**最高裁判所判事**といいます(裁判所法5条1項)。

また、下級裁判所の裁判官のうち、高等裁判所の長たる裁判官を**高等裁判所長官**といい、その他の裁判官は**判事・判事補・簡易裁判所判事**といいます(裁判所法5条2項)。

② 任命

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて、**天皇**が任命し(裁判所法39条1項)、最高裁判所判事は、**内閣**が任命します(裁判所法39条2項)。

また、高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事は、いずれも**最高裁判所の指名**した者の名簿によって、**内閣**が任命します(裁判所法40条1項)。過 19-1-1

③ 定年

最高裁判所・簡易裁判所の裁判官の定年は**70歳**、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官の定年は**65歳**であり、これに達した時に退官します(裁判所法50条)。過 19-1-2 **※3**

4 三審制

(1) 三審制とは何か

日本の裁判制度においては、3回まで裁判所の審理を受けることができる**三審制**が採用されています。過 23-2-1

この三審制によれば、第一審判決がなされた場合、上級の裁

※1 用語

人事訴訟：離婚訴訟などの家族関係に関する訴訟のこと。

※2 用語

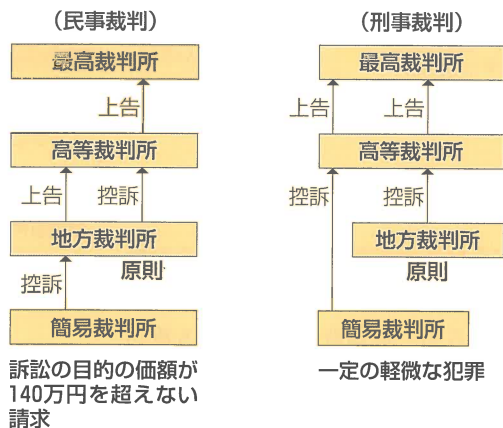
保護事件：非行に及んだ少年の更生のための処分を決定する事件のこと。

※3 過去問チェック

高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判所の裁判官については65歳の定年制が施行されているが、最高裁判所および簡易裁判所の裁判官については定年の定めが存在しない。→**×**
(19-1-2)

判所に対してその判決の取消し・変更を求める不服申立て（**控訴**）をすることができます。また、控訴審判決がなされた場合、さらに上級の裁判所に対してその判決の取消し・変更を求める不服申立て（**上告**）をすることができます。※1 ※2 ※3

【三審制】 23-2-2、元-2-ア



(2) 審理の内容

ただ回数を重ねるだけでは裁判を長引かせるだけです。民事裁判においては、事実の認定に関する事実問題は**第二審（控訴審）**までで審理しなければならず、**第三審（上告審）**では法律の解釈適用に関する法律問題についてしか審理できないのが原則です。また、刑事事件においては、事実問題は**第一審**だけで審理しなければならず、その上の審級では法律問題についてしか審理できないのが原則です。元-2-エ

ただし、判決に影響を及ぼすべき**重大な事実の誤認**がある場合などは、上告審においても事実問題を審理することができます（刑事訴訟法411条3号）。元-2-エ

(3) 上級審の審理の方式

上級審の審理の方式には、以下の3種類があります。

※1 参考

特許庁がなした審決に対する訴えのように、高等裁判所が第一審裁判所になることもある（特許法178条1項）。23-2-1

※2 参考

刑事訴訟のみならず民事訴訟においても、再審（確定判決に重大な瑕疵がある場合に、確定判決の取消しと事件の再審理を求めること）の制度が認められている（刑事訴訟法435条、民事訴訟法338条）。23-2-4

※3 参考

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。元-2-オ

続審	第1審の裁判の審理を基礎としながら、上級審においても新たな訴訟資料の提出を認めて審理を続行するもの
事後審	第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの
覆審	第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの

民事訴訟における控訴審の裁判は**続審**、刑事訴訟における控訴審の裁判は**事後審**とされています。図元-2-イ・ウ

5 司法制度改革

(1) 裁判員制度

裁判員制度とは、一定の重大犯罪に関する刑事裁判の第一審において、一般市民が裁判官と合議体を構成し、審理・評決を行う制度のことです。この裁判員制度は、司法制度改革の一環として、2009年から実施されたものです。

裁判員制度の対象となる裁判においては、裁判員**6人**、裁判官**3人**（例外的に裁判員4人、裁判官1人の場合もあります）で構成される合議体が、**事実の認定・法令の適用・刑の量定**を行います。そして、この合議体における判断は、裁判官及び裁判員の**双方の意見を含む**合議体の員数の**過半数**の意見によることとされています。※4

なお、裁判員制度の流れは以下ようになります。

【裁判員制度の流れ】



※4 よくある質問



Q 「裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」ってどういう意味ですか？



A ①合議体の員数の過半数の賛成のみならず、②裁判官・裁判員それぞれ1人以上の賛成が必要という意味です。例えば、裁判員6名、裁判官3名、合計9名で合議体を構成している場合、①賛成が5名以上で、かつ、②その5名の中に裁判官・裁判員の両方が入っていることが必要です。

最重要判例

● 裁判員制度の合憲性（最大判平23.11.16）

事案

覚せい剤営利目的輸入罪などで起訴された被告人が、裁判員裁判によって懲役9年及び罰金400万円の有罪判決を受けたため、裁判員制度が憲法に違反するとして争った。

結論

裁判員制度は憲法に違反しない。

判旨

①刑事裁判の基本的な担い手について

裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代民主主義国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならない、それには高度の法的専門性が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、三権分立の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。図28-1

②国民の司法参加について

他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、民主主義の発展に伴い、国民が直接司法に参加することにより裁判の国民的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の民主主義国家の多くにおいて陪審制が参審制が採用されていた。図28-1

第1 過去問チェック

日本司法支援センター（法テラス）が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。→○（25-2-オ）

(2) 日本司法支援センター（法テラス）

日本司法支援センター（法テラス）は、司法制度改革の一環として、総合法律支援法に基づき、平成18年4月に設立されたものです。日本司法支援センターは、国民の司法へのアクセス拡充のため、以下のような業務を行っています。図25-2-オ※1

【日本司法支援センターの業務】

情報提供 業務	利用者からの問合せに応じて、裁判等の法的紛争を解決するための法制度に関する情報、弁護士や隣接法律専門職の業務及び弁護士会や隣接法律専門職者の団体の活動に関する情報を無料で提供する業務 図21-2-1
民事法律 扶助業務	利用者からの個別の依頼に応じて、法的紛争の解決方法について指導・助言を無料で行い、利用者の資力が十分でない場合には、弁護士や隣接法律専門職の中から適当な者を紹介して、その報酬・費用を立て替える業務 図21-2-2
国選弁護 関連業務	刑事事件の被告人又は被疑者に国選弁護人を付すべき場合において、裁判所からの求めに応じて国選弁護人の候補を指名して通知を行い、選任された国選弁護人にその事務を取り扱わせて、その報酬・費用を支払う業務 図21-2-3
司法過疎 対策業務	いわゆる司法過疎地域において、利用者からの個別の依頼に応じ、相当の対価を得て、弁護士や隣接法律専門職に法律事務を取り扱わせる業務 図21-2-4
犯罪被害 者支援 業務	犯罪の被害者やその親族等に対して、刑事手続への適切な関与やその損害又は苦痛の回復・軽減を図るための制度その他被害者やその親族等の援助を行う団体等の活動に関する情報を無料で提供する業務 図21-2-5

(3) 刑事裁判に関する改革

① 強制起訴

平成16年の検察審査会法改正により、検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する**強制起訴**の制度が導入されました。図25-2-エ

② 公判前整理手続

平成17年の刑事訴訟法改正により、刑事裁判においては、審理が開始される前に事件の争点及び証拠等の整理を集中して行う**公判前整理手続**の制度が導入されました。図25-2-ウ

(4) 消費者団体訴訟制度

① 差止め請求

平成18年の消費者契約法改正により、事業者による不当な勧誘行為・表示行為等について、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる**消費者団体訴訟制度**が導入されました。図25-2-ア

② 損害賠償請求

平成25年に成立した「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」により、一定の集団（クラス）に属する者（例えば、特定の商品によって被害を受けた者）が同一の集団に属する者の全員を代表して原告となり、当該集団に属する者の全員が受けた損害について、一括して損害賠償を請求することができるようになりました。 25-2-イ

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ 1 日本では、民事裁判においても刑事裁判においても、自由心証主義が採用されている。
- ☐ ☐ ☐ 2 下級裁判所は、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所の3種類だけである。
- ☐ ☐ ☐ 3 日本の裁判制度においては、3回まで裁判所の審理を受けることができる三審制が採用されている。
- ☐ ☐ ☐ 4 裁判員制度とは、一定の重大犯罪に関する刑事裁判の第一審・控訴審及び上告審において、一般市民が裁判官と合議体を構成し、審理・評決を行う制度のことである。

解答 1 ○（民事訴訟法247条、刑事訴訟法318条） 2 × 家庭裁判所も加えた4種類である（裁判所法2条1項）。 3 ○ 4 × 裁判員制度が採られるのは、刑事裁判の第一審のみである。



学習のPOINT

裁判外紛争解決手続については、裁判制度ほど頻出ではないので、和解・あっせん・調停・仲裁といった各種の方法について一読しておけば十分でしょう。

1 裁判外紛争解決手続とは何か

裁判外紛争解決手続とは、裁判によらないで民事紛争を処理（解決）しようとする手続のことであり、**ADR**（Alternative Dispute Resolution）とも呼ばれます。具体的には、和解・あっせん・調停・仲裁などの手続があります。※1 図18-1-D

裁判と裁判外紛争解決手続の違いは、以下の表のとおりです。

【裁判と裁判外紛争処理手続】

	裁判	裁判外紛争解決手続
長所	厳格な手続により、慎重かつ公正な判断を受けることができる	安い費用で簡易迅速な紛争解決をすることができる
相手方の合意	不要	必要
手続の公開	原則として公開	通常は非公開
解決案の拒否	不可	調停の場合は可能、仲裁の場合は不可

2 和解

（1）和解とは何か

和解とは、紛争当事者相互の譲歩（互譲）によって争いを解消し、新しい法律関係を契約によって設定することです。

（2）種類

① 裁判外の和解（和解契約）

裁判外の和解とは、裁判所の関与なしに紛争当事者間で和解

※1 参考

ADRを実施するため、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が施行されている。

契約を締結することです。

この和解契約が成立すると、たとえ反対の確証が出たとしても、それによって何ら影響を受けないことになります（民法696条）。

② 起訴前の和解（即決和解）

起訴前の和解とは、民事紛争を訴訟によらないで処理するために、簡易裁判所に和解を申し立てることです（民事訴訟法275条）。簡易裁判所が関与している点で、単なる和解契約とは異なります。

起訴前の和解の内容を調書※1に記載したときは、その記載は、**確定判決**※2と同一の効力を有します（民事訴訟法267条）。

③ 裁判上の和解（訴訟上の和解） 図18-1-A

裁判上の和解とは、訴訟の係属中に、期日において訴訟当事者間で和解をすることです。

裁判上の和解の場合も、その内容を調書に記載したときは、その記載は、**確定判決**と同一の効力を有します（民事訴訟法267条）。

3 あっせん

あっせんとは、あっせん員が紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるもののことです。

労働争議や公害紛争処理においては、あっせんによる紛争の解決が認められています。

4 調停

(1) 調停とは何か

調停とは、裁判官（調停主任）1人と民間人の調停委員2人以上で構成される調停委員会が、紛争当事者を仲介して紛争を処理する手続のことです。

この調停は、法の基準によるのではなく、当事者の互譲により条理にかなない実情に即した解決を図ることを目的とした紛争

※1 用語

調書：訴訟手続などの経過・内容を公証するために作成される文書のこと。

※2 用語

確定判決：通常の上訴という手段では取り消すことのできない状態に至った判決のこと。

解決方法です。図18-1-B、2-1-A

(2) 調停前置主義

家事事件手続法に基づき調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません（家事事件手続法257条1項）。これを**調停前置主義**といいます。※3 図18-1-B

このように調停前置主義が採用されたのは、合意による紛争処理を促進するためです。

※3 具体例をイメージ

例えば、離婚事件などである。

5 仲裁

仲裁とは、紛争当事者が争いの解決のために第三者（仲裁人）を選び、その判断によって紛争を解決することです。これは、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきたものです。図18-1-C、2-1-U

この仲裁においては、第三者の仲裁判断に当事者が拘束される点が特徴的です。

確認テスト

- ☐ ☐ **1** 和解・あっせん・調停・仲裁等の裁判によらないで民事紛争を処理しようとする手続のことをPFIという。
- ☐ ☐ **2** 起訴前の和解の内容を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
- ☐ ☐ **3** 家事事件手続法に基づき調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない。
- ☐ ☐ **4** 仲裁においては、第三者の仲裁判断に当事者が拘束されるわけではない。

解答

1 × ADRである。 **2** ○（民事訴訟法267条） **3** ○（調停前置主義：家事事件手続法257条1項） **4** × 仲裁判断に当事者は拘束される。